

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2982/2562

พนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โจทก์

เด็กหญิง ส. โดยนางสาว บ. ผู้แทนโดย

ชอบธรรม

ผู้ร้อง

นาย ค.

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1, มาตรา 2, มาตรา 3, มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม), มาตรา 279 วรรคสี่, มาตรา 279 วรรคห้า (ใหม่), มาตรา 283 ทวิ วรรคสอง, มาตรา 317 วรรคสาม

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 มาตรา

ผู้เสียหายที่ 2 วิ่งไปหาจำเลย จำเลยกอดผู้เสียหายที่ 2 แล้วจับหน้าผาก จากนั้นถอดกางเกงผู้เสียหายที่ 2 ออกแล้วอุ้มผู้เสียหายที่ 2 ใช้นิ้วมือสอดเข้าไปในทวารหนักของผู้เสียหายที่ 2 โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยอุ้มพาผู้เสียหายที่ 2 ไปที่อื่น จำเลยล่องเกินทางเพศผู้เสียหายที่ 2 ตรงบริเวณที่พบผู้เสียหายที่ 2 นั้นเอง เท่ากับว่าผู้เสียหายที่ 2 มาหาจำเลยเองด้วยความเต็มใจ จำเลยมิได้พาผู้เสียหายที่ 2 มา อีกทั้งมิได้เหนี่ยวรั้งผู้เสียหายที่ 2 ไว้ เช่นนี้ ย่อมถือไม่ได้ว่าจำเลยมีการกระทำการใดอันเข้าลักษณะเป็นการพรากผู้เสียหายที่ 2 ไปเสียจากผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งจะกระทบกระเทือนต่ออำนาจปกครองของผู้เสียหายที่ 1 จำเลยจึงไม่มีความผิดตาม ป.อ.

มาตรา 317 วรรคสาม และย่อมไม่มีความผิดฐานพาผู้เสียหายที่ 2 เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจารด้วย

ในระหว่างการศึกษาของศาลฎีกา มี พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 ออกใช้บังคับ โดยมาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อเนื่องเป็น (18) ของมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา "(18)" "กระทำชำเรา" หมายความว่า "การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น" มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 277 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและให้ใช้ความใหม่แทน แต่ความใหม่มิได้บัญญัติให้การใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น เป็นความผิดฐานกระทำชำเรา และมาตรา 9 ให้ยกเลิกความในมาตรา 279 แห่งประมวลกฎหมายอาญาให้ใช้ความใหม่แทน โดยมาตรา 279 วรรคสี่ บัญญัติว่า "ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม เป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่น ซึ่งมีใช้อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษ..." และวรรคห้า บัญญัติว่า "ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสี่เป็นการกระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปีต้องระวางโทษ..." ดังนั้นจากบทบัญญัติของกฎหมายที่แก้ไขดังกล่าว ยังคงบัญญัติว่าการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมีใช้อวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นยังเป็นความผิดอยู่ มิได้เป็นเรื่องที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังบัญญัติให้การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปตาม ป.อ. มาตรา 2 วรรคสอง เพียงแต่เปลี่ยนฐานความผิดจากการกระทำชำเราเป็นความผิดฐานอนาจารโดยการล่วงล้ำเท่านั้น ซึ่งตามสภาพทางธรรมชาติในการกระทำความผิดของจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) จึงเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่าการกระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) การปรับบทความผิดของจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) จึงเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่าตาม ป.อ. มาตรา 3 แต่ความผิดฐานกระทำอนาจารโดยการล่วงล้ำตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรค

ห้า (ที่แก้ไขใหม่) มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต ส่วนความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต ระวางโทษตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่จึงไม่เป็นคุณแก่จำเลย ศาลต้องพิจารณาลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่จำเลยกระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา 2 วรรคหนึ่ง ปัญหานี้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและปรับบทลงโทษจำคุกให้ถูกต้องได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 277, 283 ทวิ, 317

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางสาว บ. ผู้เสียหายที่ 1 ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหายที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทน 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การในคดีส่วนแพ่งขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม), 283 ทวิ วรรคสอง, 317 วรรคสาม การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร กับฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม เป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี โดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 7 ปี ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจาร จำคุก 5 ปี คำเบิกความของจำเลยในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษกระทงละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 7 ปี 12 เดือน กับให้จำเลยชดใช้เงิน 65,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้เสียหายที่ 2

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 ทวิ, 317 ส่วนโทษฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยเมื่อลดโทษให้หนึ่งในสามแล้ว คงจำคุก 4 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เพียงประการเดียวว่า จำเลยกระทำความผิดฐานพรากผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากนางสาว บ. ผู้เสียหายที่ 1 มารดาผู้ใช้อำนาจปกครองดูแลเพื่อการ

อนาจาร กับฐานพาผู้เสียหายที่ 2 เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีเพื่อการอนาจารด้วยหรือ ไม่ สำหรับความผิดฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสาม นั้น คำว่า "พราก" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 มีความหมายว่า จากไป พาเอาไปเสีย แยกออกจากกัน เอาออกจากกัน ดังนั้น การพรากซึ่งจะทำให้ผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสาม จึงหมายถึงการพาหรือแยกเด็กออกไปจากอำนาจปกครองดูแลของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ทำให้อำนาจปกครองดูแลเด็กของบุคคลดังกล่าวถูกระงับหรือถูกกระทบกระเทือนโดยบุคคลดังกล่าวไม่รู้เห็นยินยอมด้วย อันเป็นการล่วงละเมิดอำนาจปกครองของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก คดีนี้ได้ความตามคำให้การในชั้นสอบสวนของผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งตรงกับที่มีการบันทึกไว้ในวิดิทัศน์ว่าขณะผู้เสียหายที่ 2 วิ่งเล่นอยู่ที่ข้างบ้าน สังเกตเห็นจำเลยซึ่งผู้เสียหายที่ 2 รู้จักมาก่อน ขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเข้าไปที่บ้านร้างภายในสวนปาล์ม ผู้เสียหายที่ 2 จึงวิ่งเข้าไปหาจำเลย จำเลยกอดผู้เสียหายที่ 2 แล้วจูบหน้าผากผู้เสียหายที่ 2 จากนั้นถอดกางเกงผู้เสียหายที่ 2 ออกแล้วอุ้มผู้เสียหายที่ 2 ใช้นิ้วมือสอดเข้าไปในทวารหนักของผู้เสียหายที่ 2 โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยอุ้มพาผู้เสียหายที่ 2 ไปที่อื่นหลังจากผู้เสียหายที่ 2 วิ่งเข้ามาหา จำเลยล่วงเกินทางเพศผู้เสียหายที่ 2 ตรงบริเวณที่พบผู้เสียหายที่ 2 นั้นเอง เท่ากับว่าผู้เสียหายที่ 2 มาหาจำเลยเองด้วยความเต็มใจ จำเลยมิได้พาผู้เสียหายที่ 2 มา อีกทั้งมิได้เหนี่ยวรั้งผู้เสียหายที่ 2 ไว้ เช่นนี้ ย่อมถือไม่ได้ว่าจำเลยมีการกระทำประการใดอันเข้าลักษณะเป็นการพรากผู้เสียหายที่ 2 ไปเสียจากผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งจะกระทบกระเทือนต่ออำนาจปกครองของผู้เสียหายที่ 1 จำเลยจึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสาม และย่อมไม่มีความผิดฐานพาผู้เสียหายที่ 2 เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจารด้วย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7

พิพากษายกฟ้องโจทก์ในความผิดทั้งสองข้อหานี้ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยที่ใช้นิ้วสอดใส่เข้าไปในทวารหนักของผู้เสียหายที่ 2 เป็นความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 หรือไม่ เห็นว่า ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 27 พ.ศ.2562 ออกใช้บังคับ โดยมาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อนี้เป็น (18) ของมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา "(18)" "กระทำชำเรา" หมายความว่า "การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล้วงล้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น" มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 277 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความใหม่แทน แต่ความใหม่มิได้บัญญัติให้การใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น เป็นความผิดฐานกระทำชำเรา และมาตรา 9 ให้ยกเลิกความในมาตรา 279 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้ใช้ความใหม่แทน โดยมาตรา 279 วรรคสี่ บัญญัติว่า "ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม เป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นใด ซึ่งมีใช้อวัยวะเพศล้วงล้าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษ..." และวรรคห้า บัญญัติว่า "ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสี่เป็นการกระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษ..." ดังนั้นจากบทบัญญัติของกฎหมายที่แก้ไขดังกล่าว ยังคงบัญญัติว่าการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมีใช้อวัยวะเพศล้วงล้าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นยังเป็นความผิดอยู่ มิได้เป็นเรื่องที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังบัญญัติให้การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง เพียงแต่เปลี่ยนฐานความผิดจากการกระทำชำเราเป็นความผิดฐานอนาจารโดยการล้วงล้าเท่านั้น ซึ่งตามสภาพทางธรรมชาติในการกระทำความผิดของจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) จึงเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่า

การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) การปรับบทความผิดของจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) จึงเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 แต่ความผิดฐานกระทำอนาจารโดยการล่วงล้ำตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต ส่วนความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต ระวางโทษตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่จึงไม่เป็นคุณแก่จำเลย ศาลต้องพิจารณาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่จำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคหนึ่ง ปัญหานี้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและปรับบทลงโทษจำคุกให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) โดยให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) สำหรับโทษและนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7

(ธนสิทธิ์ นิลกำแหง-สิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล-จรัญ รัตตมณี)

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - นางสาวพิชชาภา สาครมณีรัตน์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายสังคม สุภาพล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น๑2391/2558

๒
ต้น

หมายเหตุ